

论文编号	
------	--

中国政法大学法学院
第十二届军都法学论文大赛
参赛论文

占有的法律结构：溯源、分析与检讨
——基于霍菲尔德分析法学理论

论文方向： 民法学

提交日期： 2022 年 12 月 18 日

占有的法律结构：溯源、分析与检讨

——基于霍菲尔德分析法学理论

【摘要】

占有是一个拥有悠久历史的复杂概念。从罗马时期开始，占有概念的变迁即是一部“占有心素消亡史”，经过各国理论与制度的改造，占有的形态已然各异。但即使如此，占有背后的法理却是不变的，用霍菲尔德分析法学可以很好地阐释它的法律结构，而其中的权利部分表现为四种基本结构及其组合。《民法典》对占有制度的规定并不详尽，需要结合法律结构“占有”概念进行类型化“实证研究”，进而进行反思与检讨：将第458条所论“占有”解释为“间接占有”可以填补法律漏洞。

【关键词】占有制度 占有历史 间接占有 霍菲尔德

LEGAL STRUCTURE OF POSSESSION: REVIEW, ANALYSIS AND CRITICISM

——BASED ON THE HOHFELD'S ANALYSIS LEGAL THEORY

【ABSTRACT】

Possession is a complex concept with a long history. Since the Roman period, the change of the concept of possession is a "history of animus possidendi ". After the transformation of theories and systems in various countries, the forms of possession have been different. But even so, the legal principle behind possession remains unchanged, and its legal structure can be well explained by Hohfeld's analytical legal theory, in which the right part is represented by four basic structures and their combinations. The provisions of the Civil Code on the possession system are not exhaustive, so it is necessary to conduct a typed "empirical study" with the concept of its legal structure, and then reflect and criticize: the interpretation of "possession" in Article 458 as "indirect possession" can fill the legal loopholes.

【KEYWORDS】 possession system possession history indirect possession Hohfeld

【目录】

问题的提出与限定	1
一、占有概念的历史与比较溯源	2
(一) 罗马法占有的构成、效果与性质	2
1. 自然占有	3
2. 令状占有	3
3. 市民法占有	4
4. 罗马法占有的性质	4
(二) 大陆法系的继承与改造	5
1. 占有主观说	6
2. 占有客观说	7
(三) 英美法系的经验与启示	8
1. 英美法系中占有的历史定位	8
2. 英美法系中占有的权利倾向	9
3. 英美法系中占有的保护	9
(四) 小结	10
二、占有理论的霍菲尔德式分析	10
(一) 法律概念与非法律概念	10
(二) 占有的事实面向：构成性事实与证明性事实	12
(三) 占有的权利面向：诸法律关系之比较	13
1. 占有原权	15
2. 占有本权	16
3. 间接占有	18
4. 占有辅助	19
5. 关于动产的处分与交付	20
(四) 小结	20
三、《民法典》占有制度的反思与检讨	21
(一) 《民法典》“占有”一词的理论分类	22
(二) 基于理论分类的归纳与检讨	24
结论	25
参考文献	26

问题的提出与限定

占有是什么？这是民法的一个秘密。罗马时期伊始，民法学家们对占有本质的追问从未停止，占有相关的学说亦层出不穷，时至今日，各国学界就占有本质的讨论仍有推陈出新之势，尚无绝对通说占据统治地位。占有问题之所以如此引入注目，原因大概有两点：第一，占有具有理论重要性，作为民法理论中连接物权与债权两条“任督二脉”的关键概念，占有对于民法的体系化有着难以言喻的重要性，民法中许多概念^①承担着物债二分的重要使命，而其中绝大多数都与占有相关；第二，占有具有实践重要性，“占有乃是社会形成之初，确定财产权归属的初始规则。”^②对财产进行排他的管领与控制，是行使财产权的基础，法律规定不过是对此种自然秩序的一种肯定。受制于理论的分化，不同国家和地区的占有制度亦呈现出多样性，但无一不对其进行细致的规定，我国此前的物权法与现今的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）亦设专章规定占有制度。有趣的是，各国（地区）虽占有制度各异，但由此形成占有法律秩序并无较大差异，一个兼具诱惑力与挑战性的问题横亘在我们面前：对于占有而言，是否存在一个普适性的法律结构？如果有，如何表达？

霍菲尔德分析法学对事实与权利的考察有着不同于传统民法的全新视角，其高度形式化的特点恰是解决此问题的关键，本文意欲以此给出一个答案。为了实现这一目的，本文的第一部分将对既有的占有制度溯本寻源，从罗马法出发，以历史的视角考察占有理论的起源及各国制度如何变迁；第二部分以霍菲尔德分析法学为工具，在各国的学说与制度的基础上进行“提纯”，对占有进行概念阐释与逻辑分析，得到纯化的占有法律结构；第三部分，以上述占有法律结构为模型，反思并检讨《民法典》的占有制度，对相关规范予以必要的解释乃至续造，以期实现法教义学的完满。

在展开论述之前，还有必要对本文的问题意识及论述对象进行一定的限定，盖因占有涉及民法的方方面面，若展开论述，恐如山如海，非本人力所能及。首先，就问题意识而言，本文意欲回答“占有是什么”（what is the possession），而非“为什么要保护占有”（why should we protect the possession）。换言之，本文旨在探寻占有的本质及其形成的规范地位，而非占有保护的缘由。事实上，虽然在占有的发展史上占有的本质与其保护缘由常常彼此纠缠，但两者之间并

^① 例如所有权、他物权、交付、“买卖不破租赁”等民法概念与现象。

^② 朱庆育：《物权行为的规范结构与我国之所有权变动》，载《法学家》2013年第6期。

不具有必然联系^③。故此，本文尽量进行概念与法律关系分析，不对占有的保护进行价值上的追问——“占有值得被保护”这一结论作为前置条件参与本文的论证。其次，本文内容主要集中于占有的归属与保护，意在描述占有的保护功能，无意于详细探讨占有的表象功能——例如占有在交付、先占、善意取得等制度中表现出来的性质^④。但是，本文得到的基本结构能够衔接整个占有制度乃至整个民法，也就是说，本文所采方法对占有的分析，只有篇幅的限制，没有能力的限制。

一、占有概念的历史与比较溯源

占有的源头在罗马，罗马法是占有概念的“起源地”与“素材库”，本部分也将从罗马法开始，着重梳理大陆法系占有概念及的流变，突出变化的原因及效果，为后文的理论统一提供素材。此外，一般认为，罗马法的占有概念也对英美法系的相关制度产生了深远的影响，而英美法系有着良好的“财产权相对关系”理念土壤，其对霍菲尔德分析法学具有天然的亲和性，在此一并梳理。

（一）罗马法占有的构成、效果与性质

当我们因为困惑而回到罗马时，罗马法似乎并没有使问题变得更加清晰易知。罗马法有关占有的原始文献卷帙浩繁，古典法学家之间尚有争议，这一切无疑加深了统一的难度，对此，意大利法学家博萨（Bozza）曾发出感叹：“当我们为了理解罗马法的占有概念向原始文献寻求帮助时，我们会发现原始文献不仅没有给出一个明确定义（这一点对其他概念也一样），甚至没有明确说明其构成要件……正因如此，占有概念成为了民法中最富争议的概念，也成为了从注释法学家到我们所有这些罗马法学者所怨恨的对象。”^⑤此外，还应注意并克服的一个困难是，优士丁尼在编纂法典之时，对占有的相关论述进行了改变与混淆，从而使得古典占有更加面目全非，下文的具体论述将指出这一点。不过即便如此，回到罗马也是重要的，作为本源的罗马法蕴含着占有最原始的法律构造，是后人理论创新的渊薮，即使它们已经不再适合复杂多变的现代社会，我

^③ 吴香香教授对此有三重否定：第一，占有本质问题并非占有保护缘由的先决问题；第二，占有本质问题不会影响占有保护的实质理由；第三，占有本质问题不会影响占有保护规范法具体设置与解释。参见吴香香：《占有保护缘由辨》，载王洪亮等主编《中德私法研究》（第11卷），北京大学出版社2015年版，第14页-17页。

^④ 两种占有功能的具体内涵与区分参见吴香香：《功能视角下的占有概念》，中国政法大学2010年博士论文。

^⑤ F.Bozza, *Il possesso*, Napoli, 1935, p.1. 转引自贾婉婷：《罗马物权法——所有权与占有》，中国法制出版社2019年版，184-185页。

们也有必要将其发掘出来。

在罗马法古典文献里，“占有”（*possessio*）一词并非最小概念单元，罗马法学家在论述“占有”之时，所表达的并非同一含义。此背景下，可行的方法是，确定不同文献里的“占有”的真实含义，并将相同含义予以类型化，提炼出更基本的术语。很多罗马法学者已经完成了此工作。在罗马法中，我们至少可以得到三个重要概念^⑥：

1. 自然占有

自然占有（*possessio naturalis*），指占有的体素（*corpore*），是指对物事实上的管领与支配。自然占有并不要求占有主体持续接触某物，即使一物没有持续地处在主体的控制范围内，依照一般社会观念判断主体仍得控制，也认为主体对该物存在着持续的占有，这种现象在民法理论中称为“占有观念化”，现代人较容易理解此种现象，例如将车停在停车场，虽暂时丧失对车的控制，但依照日常经验来看车主并不丧失对车的占有。占有观念化在罗马法上已有体现，譬如对整块土地的自然占有，并不要求主体踏遍每一寸土地（D. 41, 2, 3, 1）——这是十分荒谬的；再譬如，取得了仓库的钥匙就意味着取得了对仓库里货物的自然占有（D. 18, 1, 74）。“占有最初表示单纯的持有关系，这不是一种法律关系，而是一种自然关系。”^⑦自然占有是一种自然事实，在人类认知中首先以社会现象而非法律现象出现，其并非一个法律概念，独立的自然占有并不会产生法律后果。由于仅仅是一种事实，自然占有的成立与法律评价无关，奴隶、家子与妇女均可成立自然占有。自然占有不具法律效力的另一种含义是，此种事实并未进入市民法与裁判官法的调整范围。传统民法上，“持有”最为接近“自然占有”这一概念。

2. 令状占有

令状占有（*possessio ad interdicta*）（或译为“裁判官法上的占有”“有令状的占有”）。令状占有是指享有令状保护的占有，是一种法律占有，缘起于荣誉法中对公田的保护。由于公田不得被人所有，人们难以对公田进行基于所有权的保护，只能依靠市民法以外的裁判官法（荣誉法的主要组成部分）予以令状保护，对令状占有的保护原本只是一种行政管理手段。要成立令状占有，不仅要有“体素”，还要有“心素”（*animo*）（D. 41, 2, 3, 1）。“心素”是后世

^⑥ 参见[意]萨尔瓦多里科波诺，贾婉婷：《罗马法中关于占有关系的理论——兼论现代法学理论及立法》，载《比较法研究》2009年第3期，[德]萨维尼著，朱虎，刘智慧译：《论占有》，法律出版社2007年版，第6页。萨维尼所称“没有任何附加语词”的“占有”，事实上就是“令状占有”，见上述后引第44页，相同论述参见周相：《罗马法原论（上）》，商务印书馆2014年版，第460页。

^⑦ [德]萨维尼著，朱虎，刘智慧译：《论占有》，法律出版社2007年版，第44页。

占有理论发展中争议最大的概念，许多国家的制度分野多至此而始，下文将详述。一般认为，罗马法上的“心素”是指“据为己有的意思”^⑧，与传统民法上的“自主占有意思”一致，均表示一种无视返还义务的事实意思。但是，仅具有理解能力的特定主体能产生心素，精神病人与幼儿不能产生心素^⑨（D. 41, 2, 1, 3）。不过，令状占有的构成也有例外，由于现实的需要，罗马法亦规定一些具有体素的他主占有人享有令状占有，比如永佃权人、质权人、容假让与人、扣押保管人^⑩。

3. 市民法占有

市民法占有（*possessio civilis*）（或译为“法定占有”“民法占有”）。市民法占有也是一种法律占有，其构成不仅需要令状占有的全部要件，还需要“占有的正当原因”（*iusta causa possessionis*），即占有必须是基于权利基础而取得的，例如买卖、赠与、嫁资、物上遗赠、债务清偿等^⑪，这一概念非常类似传统民法上的“法律上原因”。市民法占有的法律效果是进行时效取得。由于市民法占有的构成要件涵盖了令状占有，所以对占有事实的保护是通过对令状占有的保护完成的，因此，就市民占有的特殊构成要件与法律效果来说，市民法占有充斥着权利的因子。

4. 罗马法占有的性质

有了如上的陈述，我们可以追问一个“令人苦恼的古来课题”：占有是事实还是权利？这个问题随着时代的变化有着不同的答案，在本部分，我们尝试给出罗马时期的回答。

首先，在罗马法早期的原始文献中，特别是保罗的一些篇章中能够推知，占有被认为是一种事实（D. 41, 2, 1, 4; D. 41, 2, 3, 5）；其次，到了后古典通俗法时期，占有被认为是一项事实，却关涉权利（D. 41, 2, 49, 1），同时，占有逐渐与所有权混淆：一个没有取得市民法所有权但已取得市民法占有的人，将被视为取得裁判官法所有权，并且受到布布里其之诉（善意占有之诉）（*actio Publiciana*）的保护，这一变化使得占有的轮廓更加模糊不清；最后，等到了优士丁尼时期，为了制度的简洁与统一，优士丁尼大帝废除了市民法与裁判官法的区分（C. 7, 31, 1pr.），至此，法定占有或正当占有被优士丁尼时期法学家们认为是“自成一类（*sui generis*）的真正权利”^⑫。

^⑧ 江平，米健：《罗马法基础》（修订本第三版），中国政法大学出版社 2004 年版，269 页。

^⑨ [意]阿尔贝托·布尔代塞，翟远见译：《罗马物权法》（第四版），中国政法大学出版社 2022 年版，第 178 页。

^⑩ [德]马克思·卡泽尔著，田士永译：《罗马私法》，法律出版社 2018 年版，209-210 页。

^⑪ [德]萨维尼著，朱虎，刘智慧译：《论占有》，法律出版社 2007 年版，第 208 页。

^⑫ [德]萨维尼著，朱虎，刘智慧译：《论占有》，法律出版社 2007 年版，第 177 页。

本文认为，由于罗马法拥有“市民法-裁判官法”这类二元法律渊源，我们不能贸然断定占有作为一个整体属于事实或者权利，而是应该进行分类讨论：第一，对于自然占有而言，无论是构成还是效果，自然占有均不受法律评价，游离于法体系之外，是纯粹的事实；第二，对于令状占有而言，其构成是纯粹的事实性要素（体素和心素），虽受法律保护，亦难谓之权利，应定性为能够产生法律关系的事实；第三，对于市民法占有而言，就其与令状占有有所不同的部分，构成（正当原因）与效果（时效取得）乃纯粹法律之评价，应为权利。然而，此处所用的“事实”、“法律关系”和“权利”仍然为传统民法中含混的表述，是对罗马法朴素的法律概念一个直观的反映。罗马法的缔造者们重实践而轻理论，概念不够精细是可以理解的，但这并不意味着现代的法律理论要延续这种混沌的状态。

以下图示集中展示了罗马法上三种占有的构成、效果、性质及示例^⑩。

A=体素 B=心素 C=正当原因

	构成	法律效果	性质	示例
自然占有	A	无	事实	借用人、承租人等
令状占有	A+B*	受令状保护	特殊事实	自主占有人等
市民法占有	A+B+C	时效取得	特殊事实+权利	买受人、受赠人等

*例外：永佃权人、质权人、容假让与人、扣押保管人这四类他主占有人可构成令状占有。

表 1

（二）大陆法系的继承与改造

出于编撰法典的便利，优士丁尼不再区分“市民法—裁判官法”的二元法律渊源，从而毁坏了古典占有理论的精致结构。前文我们已经看到了更加清晰的罗马法，但这也并不意味着将它放到现在仍然正确。随着社会的发展，占有的原初概念已不满足交易生活的需要，故而后世民法并未有罗马之全然继承者，现代民事立法多在此基础上进行了修正或者重塑。本部分着眼于罗马之后的大陆法系民法，力图勾勒出现代民法占有概念与制度的轮廓。

近现代民法对占有理论的发展，概括的说，就是一部“占有心素消亡史”。在罗马法上，心素的是据为己有的意思，不具有自主占有意思的人不构成令状占有（萨维尼所谓传来占有的四类人除外），仅构成自然占有。此规定直接的法律后果是，所谓的自然占有人（典型的如承租人）不受令状保护，倘若其自

^⑩ 用代数式表示各种占有的方法参见史尚宽：《物权法论》，中国政法大学出版社 2000 年版，第 529 页；[意]萨尔瓦多里科波诺，贾婉婷：《罗马法中关于占有关系的理论——兼论现代法学理论及立法》，载《比较法研究》2009 年第 3 期。

然占有为人所侵扰，他能做的只有寻求令状占有人（通常也是所有权人）行使其令状保护的權利，自己无从置喙。而随着社会的发展，“非所有人利用他人财产活动的日益普遍和自主，使财产归属对财产利用的支配力日趋减弱，财产利用逐渐回归其本身的客观属性并表现出独立的实际价值。”^⑭具言之，自然占有或者持有这种他主占有已经具备独立保护的价值。例如，几乎所有国家均设法直接保护承租人的占有。为了回应这种经济生活的需要，就必然对占有概念进行学理与制度上变更，首当其冲的便是，心素的概念随着历史的推移而不断降低其构成标准，甚至趋近于无，导致占有的概念随之扩张。以下，我们以各国的制度设置为主要线索，同时以学说争议来辅佐考察这段历史。

1. 占有主观说

占有的构成除体素外，尚需心素，此为占有主观说。此说又可细分为所有意思说、为自己意思说，可分别称为强主观说与弱主观说。^⑮

理论上，占有意思主观说最著名的作品即是萨维尼的《论占有》，在其中，萨维尼通过对罗马原始文献进行体系化解读，认为心素必须通过 *animus domini*（支配意图）或 *animus sibi habendi*（据为己有的意图）得到解释，虽然这个观点“没有出现在《法学阶梯》与《学说汇纂》中，但他无疑处处被作为前提”。^⑯萨维尼建立了以心素为核心的占有理论体系，此理论直接影响了《法国民法典》的占有制度创设。

制度上，采此种立法例的国家有法国、奥地利、意大利等^⑰，统称为法国派。只具有体素不具有心素的事实，被称为“持有”，持有因此不享有时效取得的利益，却能够行使占有保护的權利^⑱，例如，承租人并不享有占有，却因为享有持有，得以行使占有保护的權利。法国派无疑是罗马法的忠实继承者，“占有”与“持有”的区分，基本上延续了罗马法上“市民法占有”与“自然占有”对立的格局；但同时，由于社会发展对占有保护扩张的需要^⑲，法国派将“令状占

^⑭ 孟勤国：《占有概念的历史发展与中国占有制度》，载《中国社会科学》1993年第4期。

^⑮ 学说上所谓“支配意图说”，在本文看来与后文狭义客观说并无实质区别，故省略。另外，由于“为自己意思说”仅有日本民法采之，且日本学界对此说尚有批判，故下文主要论述“所有意思说”。日本学界的批判参见[日]我妻荣著，罗莉译：《新订物权法》，中国法制出版社2008年版，第477页。

^⑯ [德]萨维尼著，朱虎，刘智慧译：《论占有》，法律出版社2007年版，第79页。

^⑰ 《法国民法典》第2255条：“对我掌管之物或行使之权利的持有或享有，或者，对由他人以我之名义掌管之物或行使之权利的持有或享有，谓之占有。”；《奥地利普通民法典》第309条：“使物在其支配力或管领力之下者，称为物的持有人。物的持有人具有物属其所有之意思者，称为物的占有人。”；《意大利民法典》第1140条：“占有，是在适应所有权或者其他物权的行使的活动方面所表现的物上的力量。占有得直接为之，亦得由所持物的他人介在为之。”

^⑱ 参见《法国民法典》第2278条，《意大利民法典》第1168条，《奥地利民法典》无相应规定，似有不同，参见[奥]伽里布菴·库齐奥，[奥]海尔穆特·库齐奥著，张玉东译：《奥地利民法概论——与德国法相比较》，北京大学出版社2019年版，第85页。

^⑲ 举例而言，对于“承租人是否享有占有保护”的问题，法国学者一针见血的指出，“哲理的争论多半出于假想，事实上，承租人是否有权提起占有权诉讼，完全取决于承租人所具有的社会地位和经济独立的程度。”法国派的嬗变，体现出一种实用主义的制度取向。参见尹田：《法国物权法》（第二版），法律出版社2009年版，第170页。

有”的法律效果赋予给了“持有”，这样的变更虽然有别于罗马法，但其中的概念技术设计实际并无创新之处。值得一提的是，在《德国民法典》的立法进程中，早期的《德国民法典第一草案》（以下简称《第一草案》）也深受罗马法与萨维尼理论的影响，占有需要内容为“以所有意思”（Aneignungswillen）的心素为必要^{②①}，与法国派大同小异。最终成型的《德国民法典》却废弃了这一设计，这一立法变迁正可体现占有理论发展的客观化转向。

2. 占有客观说

将占有意思与体素一同并入客观要素，甚至直接抛弃占有意思，是谓占有意思客观说。

理论上，占有意思客观说具体可分为狭义客观说和纯客观说，狭义客观说为耶林首创，他认为“真正的根据并不在于占有意思的独特形式，而且此意思在任何情形只需要指向于对物进行控制即可。”²¹即心素为体素不可分割的一部分，且到达控制意图已足够，并不用到达所有意思；纯客观说则为贝克尔提出²²，主张抛弃占有意思，存在事实上的管领即存在占有。占有意思客观说对当时以萨维尼占有理论为中心的主流学说进行了深刻的批判，耶林认为，萨维尼的《论占有》只是“一颗具有短暂意义的璀璨流星”，只有“文献史方面的价值”²³；而贝克尔认为“当时法学的任务是摧毁共同法的教义，撼动其基石，创造材料，‘以达到新的高地’。”²⁴另外，与理论冲击并行的是日耳曼民族精神的现实力量，许多法学家认为，以罗马法古老的 Possessio 取代日耳曼民族同样古老的 Gewere 不利于德意志民族感情，而后者正是体现日耳曼民族“以手护手”精神的“权占”制度，亦是间接占有制度的源头。最终，民族感情战胜了罗马法。

制度上，上文提及的《第一草案》一经出台便引起了广泛的争议，占有意思客观说极大地冲击了当时的立法，以至于《第二草案》乃至最终的《德国民法典》彻底改变了占有制度的规定。《德国民法典》第 854 条规定：“对于物有事实上管领之力者，取得该物之占有”，实际上已采占有心素客观说。相同的立法例有瑞士，中国台湾地区²⁵。此种体例不仅将一切持有均视为占有（占有辅助除外），其上均享有占有保护，甚至创制出了一种特别的“占有”，即间接

^{②①} Werner Schubert, Die Entstehung der Vorschriften des BGB über Besitz und Eigentumsübertragung, Berlin, 1966, S. 57-95. 转引自王洪亮等主编：《中德私法研究》（第 11 卷），北京大学出版社 2015 年版，第 127 页。

²¹ Rudolf von Jhering, DER Besitz, in: Jherings Jahrb. für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen privatrechts, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1893, S. 41-98. 转引自王洪亮等主编：《中德私法研究》（第 11 卷），北京大学出版社 2015 年版，第 96 页。

²² Bekker, zur Reform des Besitzrechts, Jherings Jahrb, Bd.30, S. 235-262. 转引自史尚宽：《物权法论》，中国政法大学出版社 2000 年版，第 529 页。

²³ 同上注 21，第 108-109 页。

²⁴ 同上注 21，第 125 页。

²⁵ 《瑞士民法典》第 919 条：“对物有事实上管领者，为该物的占有人。”；我国台湾地区“民法”第 940 条：“对于物有事实上管领之力者，为占有人。”

占有制度²⁶，来解决现实控制与占有保护脱钩的问题。这种创制形成了异于罗马法传统的“双重占有”，事实上已经破坏了占有概念的纯粹性，一定程度上使我们回到了占有难以体系化的困境。

综上所述，无论是理论上还是制度上，占有心素的地位不断衰落，最终被排除出占有构成理论，这一过程客观上使得现代占有理论愈发丰满，但同时令人眼花缭乱，似乎看不出相同之处，这将在本文第二部分予以回应。下图为大陆法系占有理论变化的概览：

心素逐渐消亡	理论分化		体素要件	心素要件	学说发端	代表立法例	占有保护
	占有主观说	强主观说	事实上管领	据为己有	萨维尼	法、意、奥	均保护持有（直接占有）与占有（间接占有/代理占有）
		弱主观说		为自己控制	德恩堡	日	
	占有客观说	狭义客观说	管领及其意思		耶林	德、瑞、中国台湾	
		纯客观说	事实上管领		贝克尔		

表 2

（三）英美法系的经验与启示

对比于源远流长的大陆法系占有理论，英美法系中有关占有的论述则显得更加零碎。原因可能在于，一方面，英美法系没有与大陆法系相类似的以“所有权—他物权”关系为中心的体系化财产权理论，故而也就丧失了编撰财产法典的动因，除英国的 1925 年的《财产法》（Law of Property Act 1925）与美国的少数州的单行法或法律汇编之外，其他的成文法源均散见于涉及交易的法律里²⁷；另一方面，英美法系具有“救济先于权利”的特点，在构建理论之时优先考虑受损利益而非先有权利，难以将权力体系化。但即便如此，由于占有在财产法上扮演着无可替代的角色，英美法系上占有制度也存在相同的设计，而两大法系之间的差异自然也是值得重视的。

1. 英美法系中占有的历史定位

在英国法上，占有在历史逻辑上拥有着比所有权更优先的地位。1066 年诺曼征服之后，英国开始施行保有（tenure）制度，封建领主拥有（own）所有的土地，普通人对其土地仅为持有（hold）——用大陆法系的眼光看，即一种占有。在此基础上，持有人并不终局性地享有土地的剩余索取权，归于封建领主的土地权利几乎等同于公法上的主权，并不参与私法构筑。而持有人拥有什么呢？答案是地产权（estate），这一概念指土地上的特定利益形态。持有人因为持有

²⁶ 瑞士民法不称间接占有，统称为占有；日本民法上称间接占有为代理占有。

²⁷ 参见高鸿钧等主编：《英美法原论（上）》，北京大学出版社 2013 年版，第 636-645 页。

（占有）而获得地产权，时至今日，这一基本结构仍未改变（我国的用益物权结构与之非常类似）。

另外，不仅原始的占有能产生权利，就连非法占有的强占人都能产生一项可以对抗除真正权利人之外任何人的 estate——“侵权性非限嗣自由保有地产”（*tortious fee simple*）²⁸，此项权利可因真实权利人的放弃（*release*）而升格为合法完满的权利。值得一提的是，*estate* 是英美财产法上非常重要的概念，是英美财产法的基础，有学者论述称：“英国财产法的概念结构中，真实所有权和占有性产权之间的区别的实质只是，在先和在后取得占有之间的差别。”²⁹可见英美法系中占有的优先性与基础性。

2. 英美法系中占有的权利倾向

传统英美法系里也有三个重要的占有概念，分别是 *occupation*、*possession* 和 *seisin*³⁰。

Occupation 是指客观事实上的占有，与大陆法系的自然占有/持有/直接占有差不多。*Possession* 是一种法律占有，它要求占有人以行为对外支配其表见权益（*apparent interest*），是 *title* 的重要构成，甚至与其等同。*Possession* “是一种实体权利或权益（*a substantive right or interest*），它独立于真实所有人的权利而存在，并拥有其法律效果和利益。”³¹。

Seisin 除极个别情况下几乎等同于 *possession*，但是却多了更多的权属元素，“其（*seisin*）是占有，但却是一个和权利融为一体、密不可分的占有。”³²*seisin* 还可与事实上的占有相分离，例如，定期地产人虽然占有着土地，但并没有 *seisin*，甚至有学者论述称“所谓 *Seisin*，不那么严格地说，就是日耳曼法上的法定占有（*Gewere*）”³³可见，英美法系上的占有也有着罗马法与日耳曼法的影子，一定程度上体现出两大法系之间的交融。

3. 英美法系中占有的保护

英美法系中占有保护很大程度上也体现着一种历史的循环。若占有遭受侵害，一方面，可依据占有本权提起诉讼，类似于大陆法系的所有权返还之诉，表现

²⁸ Frederick Pollock, Robert Samuel Wright, *An Essay on Possession in the Common Law*, Oxford At The Clarendon Press, 1888, p.94, 中译本见[英]弗雷德里克著，于子亮译：《普通法上的占有》，中国政法大学出版社 2013 年版，第 114 页；同时参见 T. F. Martin, *Possession as a Root of Title*, 61 *University of Pennsylvania Law Review*. 647 (1913).

²⁹ W. T. Murphy and Simon Roberts, *Understanding Property Law*, Sweet & Maxwell, 3rd ed., 1998, p.60. 转引自冉昊：《论权利的“相对性”及其在当代中国的应用——来自英美财产法的启示》，载《环球法律评论》2015 年第 2 期。

³⁰ 参见赵萃萃：《英美财产法之 *Estate* 研究》，山东大学 2010 年博士论文，第 29-31 页。

³¹ 同上注 28，[英]弗雷德里克著，于子亮译：《普通法上的占有》，中国政法大学出版社 2013 年版，第 23 页。

³² 芦雪峰，李凤章：《反思占有“事实”说》，载《东方法学》2014 年第 1 期。

³³ Francis S. Philbrick, *Seisin and possession as the basis of legal titles*, *Iowa Law Review*, Vol 24, 1939. 转引自前注 32，芦雪峰，李凤章：《反思占有“事实”说》，载《东方法学》2014 年第 1 期。

为土地的驱逐之诉与动产的侵占之诉，而胜诉的前提是原告必须证明其直接占有之权；另一方面，实际占有人可针对不法行为提起单纯的侵害之诉，此时被告不得援引第三人的权利进行抗辩。但是，此种情况亦有变化，随着历史发展，一些有权恢复其任意占有而实际却并不占有的人（例如承租人，受寄人等）也得适用侵害之诉³⁴，此架构与德国间接占有人的占有保护设计并无二致。制度总是惊人地相似。

（四） 小结

在考察了占有的历史之后，我们发现世界各地的占有理论与制度有如下的特征：第一，对占有的构成有所分歧，但针对不法侵害占有行为，均保护占有的事实状态，且无须追问其合法性，权利主体并不限于实际控制人，背后的控制人亦可主张占有保护，此种保护可称为事实性占有保护；第二，对占有的性质有所分歧，但均可基于本权来保护占有，进而保护本权，此种保护且有别于单纯的占有保护，须证明权源，此种保护可称为权利性占有保护。

占有保护的此种区分是理解占有理论的关键之所在，罗马法上“市民法一裁判官法”的二元结构看似不复存在，实则草蛇灰线伏脉千里，幻化为占有之权利与事实的两种面向，参与各国或地区占有理论的构筑。为了体系的协调，法国派坚持了占有主观说，权利与事实的二分尚且清晰，德国派却采双重占有结构，致使两者模糊不清。

二、占有理论的霍菲尔德式分析

走出历史的丛林，我们希望有一个更加开阔的视野。制度设置的混乱容易让人迷失，但背后的法理却是共通的，我们正需要一个高度形式化的理论工具对占有的法理进行揭示。霍菲尔德分析法学可堪当重任，其理论已经常用来表达法律概念与制度的基本结构³⁵。为此，本部分将对占有理论进行霍菲尔德式分析，利用分析法学的形式化手段对占有进行澄清。

（一） 法律概念与非法律概念

³⁴ [英]弗雷德里克著，于子亮译：《普通法上的占有》，中国政法大学出版社 2013 年版，第 109-111 页。

³⁵ 王涌教授用霍菲尔德分析法学分析并建构私权，张永健教授用以检讨以物债二分为基础的传统民法理论，戴昕教授则用以为数据界定权利边界，相似的研究不一而足。参见王涌：《私权的分析与建构——民法的分析法学基础》，北京大学出版社 2019 年版；张永健：《物权的关系本质 基于德国民法概念体系的检讨》，载《中外法学》2020 年第 3 期；戴昕：《数据界权的关系进路》，载《中外法学》2021 年第 6 期。

二十世纪初，美国分析法学家霍菲尔德（Wesley Newcomb Hohfeld）在耶鲁法律杂志上发表了他的两篇同名论文《司法推理中应用的若干基本法律概念》（以下简称《基本法律概念》）³⁶，展现了一个非常精致的法律关系理论，在一百多年后的今天，这套系统仍然经得起逻辑与经验的考验，并且持续推动着法律关系形式化的研究。霍菲尔德的理论可以分为三个部分，而最重要的部分是涉及法律关系（权利）的第三部分，但是这不意味着我们可以跳过前两部分。事实上，前两部分的内容对于占有的阐释非常重要，它将有助于我们区分占有的事实与权利部分，并指明它们分属哪种事实与权利。

霍菲尔德指出，“人们有一种根深蒂固的不幸倾向，即一遇到具体问题，便往往将法律因素与非法律因素搅在一起、混为一谈”³⁷，因此区分“纯法律关系”和“引起该关系的物质与精神事实”是非常有必要的。例如，当我们谈及“财产”与“合同”等概念时，我们有时并不清楚该语词指向的究竟是法律上的利益（“财产权”“债权”等）还是事实（“不动产/一片土地”“债/一份合同书”）。

“占有”也是如此，当我们说占有时我们并不清楚我们是在说“持有”这一事实状态，还是“占有权利”“占有权能”“有权占有”“有请求返还占有的权利”这类规范地位。霍菲尔德在区分法律概念与非法律概念的基础上，进一步将事实区分为构成性事实与证明性事实，将法律概念区分为八个四对基本法律关系，要明确占有的具体内涵，必须先对其进行理论定性。上述分类作图如下：

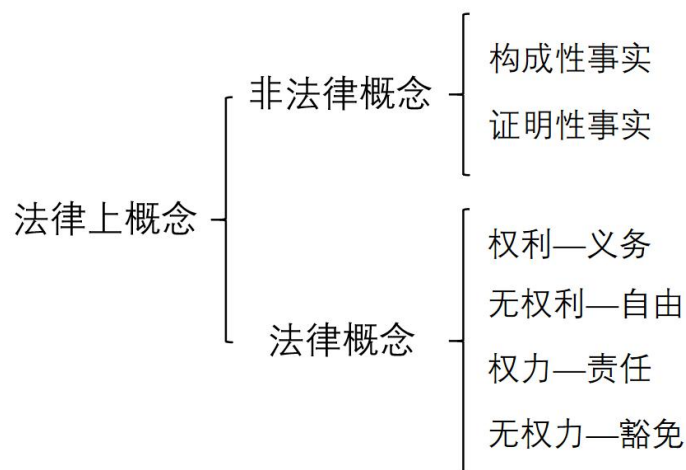


图 1

³⁶ Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, Yale University Press, 1919. 最新中译本见[美]韦斯利·霍菲尔德著，张书友译：《司法推理中应用的基本法律概念》（修订译本），商务印书馆 2022 年版。

³⁷ 同上注 36，[美]韦斯利·霍菲尔德著，张书友译：《司法推理中应用的基本法律概念》（修订译本），商务印书馆 2022 年版，第 41-42 页。

（二） 占有的事实面向：构成性事实与证明性事实

构成性事实（operative facts）是这样的一种事实，即依有效的一般法律规则足以改变法律关系者；而证明性事实（evidential facts）是另外一种事实，其一经认定，便可为推断其他事实提供（非结论性）逻辑根据。³⁸以“合同”这一概念为例，当事人之间签订的协议书，在讼至法庭之时才呈现在法官面前，而法官所见之协议书这张纸，并非“合同”本身，当事人在签订合同之时便由于一系列构成性事实（要约、承诺）而生成了法律关系，纸质的协议书仅仅作作为一种证明性事实直接或间接证实构成性事实的存在，进而推知当事人之间有“合同关系”。直觉上，这两个概念很容易理解，因为明显地，构成性事实实际上是一种法律拟制技术，这些事实并非我们的日常用语，而是足以发生法律关系变化的“法言法语”，而证明性事实只是直接或间接地证明其存在。我们可以从法理学的角度进行认识，依据法学方法论的经典原理，司法三段论的一般模式³⁹为：

[1] （1） $(Tx \rightarrow ORx)$

（2） Ta

（3） ORa （1），（2）

在这其中， x 是不特定的一般主体， a 是案件中的特定主体， T 是构成要件， R 是法律效果， O 是规范算子。作为大前提的法律规则（1），遵循着“构成要件（ T ） $\rightarrow$ 法律效果（ OR ）”的逻辑结构⁴⁰，与作为小前提的案件事实（ a 的行为）相互作用，如果案件事实（ a 的行为）满足构成要件（ T ）（2），则得出应然的法律效果（ OR ）。构成性事实与证明性事实实际上的作用是判断（2）是否成立，即判断特定主体是否符合构成要件。从这个意义上将，构成性事实与构成要件并无差异。此时，在证明案件事实（ a 的行为）是否符合 T 时，就需要给出证明性事实进行判断，观察其是否能直接或间接地证成构成性事实 T 。也就是说，以 O 表示构成性事实，以 E 表示证明性事实，上述步骤（2）：

（2） Ta

用霍菲尔德理论可表示为

（4） $E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \dots \rightarrow E_n \rightarrow O(T)$

这一个过程与法律论证理论符合的很好，进一步说明了此分类的合理性。

回到占有本身，霍菲尔德直言：“在许多情形下我们为图方便而用一个术语表达各种（一般的）事实构成。尽管这些事实构成的具体“成分”（ingredients）

³⁸ 同上注 36，[美]韦斯利·霍菲尔德著，张书友译：《司法推理中应用的基本法律概念》（修订译本），商务印书馆 2022 年版，第 49-52 页。

³⁹ [德]罗伯特·阿列克西著，舒国滢译：《法律论证理论》，中国法制出版社 2002 年版，第 275 页。

⁴⁰ 雷磊：《法律规则的逻辑结构》，载《法学研究》2013 年第 1 期。

大相径庭，却被认为具有相同的法律效果。若要细分，“占有”（possession）一词便属于上述情形……”⁴¹就占有的事实面向而言，理论上存在构成性事实与证明性事实的区别，前者表明法律上的占有地位，后者则是对现实占有的反映。在占有构成理论上，以强主观说为例，占有构成可表示为：

[2] (5) E_1 （据为己有事实） $\rightarrow O_1$ （心素）

(6) E_2 （事实上管领的事实） $\rightarrow O_2$ （体素）

(7) $O_1 + O_2 \rightarrow O_3$ （占有）

从[2]中我们可以考察到，由于各国对占有的定义不一致（O 的内容不一致，或缺少 O_1 ），想要得到一个纯化的占有构成理论是困难的，因为这并不是单纯的理论问题，更是一个制度传统与路径依赖的问题。但这并不意味着不能纯化其他部分。事实上，纯化占有的构成对占有的法律本质而言并无多大助益，因为真正起决定性作用的是占有的效果，即占有形成的法律关系。

（三） 占有的权利面向：诸法律关系之比较

霍菲尔德将法律概念化归为八个四组概念，分别是“权利（claim）—义务（duty）”“自由（privilege）—无权利（no-claim）”“权力（power）—责任（liability）”“无权力（disability）—豁免（immunity）”。这四组关系是法律关系的元形式，是法律关系的“最小公分母”。其中，“权利”“自由”“权力”“豁免”为法律上的优势地位，是广义的权利，而与之关联的则为法律上劣势地位，是广义的义务。把握霍菲尔德权利分析理论的关键是理解关联关系与相反关系，“所谓的相关（关联）关系，就是指不同主体之间的逻辑上的对等关系；所谓的相反关系，就是指相同主体之间的逻辑上的矛盾关系。”⁴²霍菲尔德的四对八个法律概念的关系如下所述：

“权利（claim）—义务（duty）”，指一方得请求另一方为或不为某行为，后者对前者负有为或不为某行为之义务。

“自由（privilege）—无权利（no-claim）”，指一方相对另一方得为或不为某行为，后者无权利要求前者为或不为某行为。

“权力（power）—责任（liability）”，指一方得通过单方行为创设法律关系，另一方必须被动承受法律关系之创设。

“无权力（disability）—豁免（immunity）”，指一方不受另一方单方创设法律关系之约束，后者没有通过单方行为创设法律关系之能力。

⁴¹ 同上注 36，[美]韦斯利·霍菲尔德著，张书友译：《司法推理中应用的基本法律概念》（修订译本），商务印书馆 2022 年版，第 52 页。

⁴² 王夏昊：《本体论同构与法律权利概念观分异——基于分析路径的权利研究》，载《法制与社会发展》2021 年第 4 期。

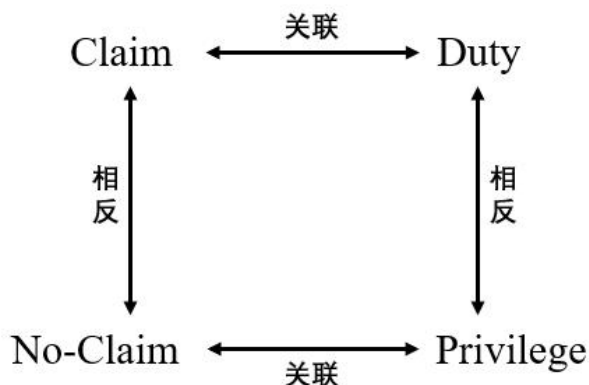


图 2

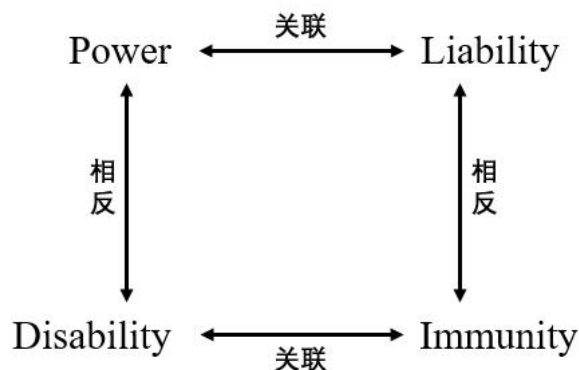


图 3

回到占有本身，占有的权利面向是非常混乱的，当我们使用“占有权”⁴³这一概念时，它可能指因事实占有而产生的权利（以下简称为“占有原权”）、占有本权、占有权能、间接占有（权）等众多概念。概念是法学理论的基石，概念的模糊势必造成体系的混乱。为此，以下尝试依次分析①占有原权（罗马的传来占有、德国的直接占有、法国的暂时持有、英美的 *possession* 等）②占有本权③间接占有（罗马的令状占有、德国的间接占有、法国的暂时持有、英美的 *seisin* 等）④占有辅助（罗马的自然占有、德国的占有辅助、日本的机关占有等）的法律结构，尝试厘清概念与概念之间关系⁴⁴。值得一提的是，本部分的分析并非“实然”分析，乃是“应然”分析，期望得到一个框架结构，而非具体规范的整理⁴⁵。事实上，具体规范的设置并非法学理论所能决定，更多的体现为

⁴³ 我国学理上有过“占有权”能否独立于“所有权”单独存在的争论，学者们对同一概念有着不同的理解，一词多义的现象可见一斑。参见孟勤国：《论占有、占有权能和占有权》，载《法学研究》1985年第2期，王利明：《关于占有、占有权和所有权问题》，载《法学评论》1986年第1期。

⁴⁴ 为了行文简洁，以下法律关系元形式均用英文表示。括号中“+”“-”分别表示作为行为与不作为行为。

⁴⁵ 对于占有保护规范设置的实证研究，参见张永健：《霍菲尔德分析法学对占有、信托概念的新界定》，载《经贸法律评论》2021年第6期。

一国（地区）统治阶级的意志。

1. 占有原权

因事实占有而产生的占有原权，是占有的核心。从罗马的令状保护到大陆法系的占有保护请求权与英美法系的侵害之诉，人类社会普遍奉行着这样的理念：事实占有不容侵夺，法律保护之。熟谙霍菲尔德理论的学者们均直指，占有是自由权⁴⁶，此论可谓切中肯綮，但亦有未尽周延之处。本文循此路径接续展开，将下文称因事实占有而产生的权利为占有原权，占有原权呈现出如下的法律结构：

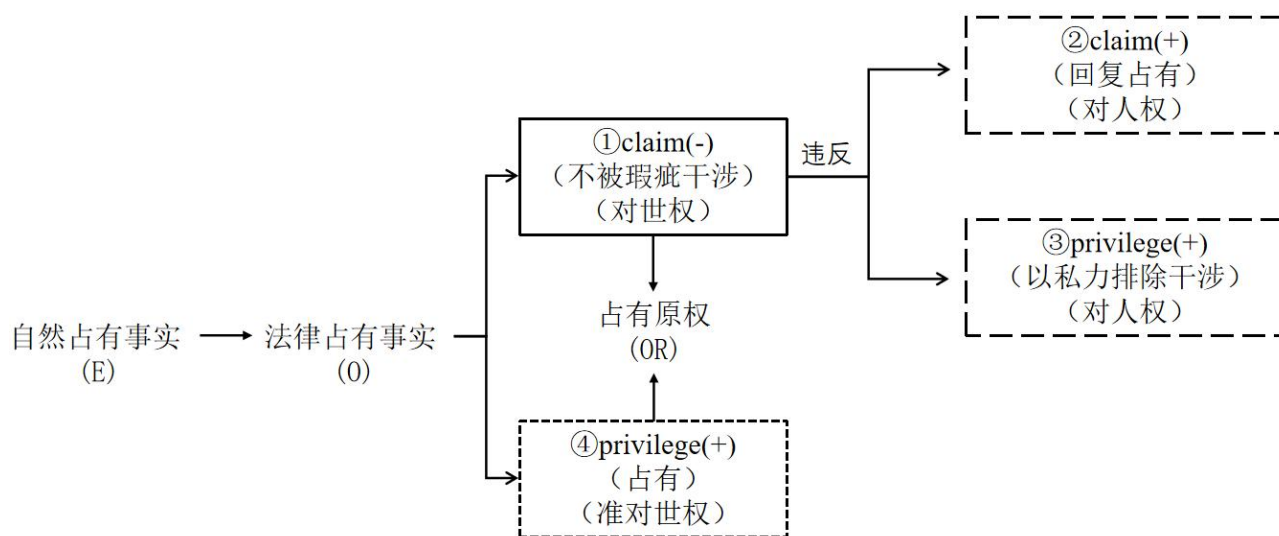


图4

①Claim A (-) —Duty A (-)：事实占有人有权利（Claim）请求世界上其他人不得瑕疵干涉其占有，世界上其他人均负有不得瑕疵干涉事实占有之占有的义务（Duty）。此系对世⁴⁷、第一性 Claim (-)。

之所以用“瑕疵干涉”，是因为“干涉”的内涵究竟为何，则是一种价值判断，不同的立法例有不同的看法。例如，就德国与我国台湾地区而言，“干涉”可分为“侵夺”“妨碍”“有妨碍之虞”，其中“侵夺”必须满足“禁止之私力”（*verbotene Eigenmacht*）要件⁴⁸，即德国民法典第858条第1款规定：“未经占有人之同意而侵夺或妨害占有者，其行为应属不法。但侵夺或妨害为法律所准许者，不在此限。”不构成“侵夺”的占有移转不产生该权利（Claim），

⁴⁶ 参见上注35王涌：《私权的分析与建构——民法的分析法学基础》，北京大学出版社2019年版，第359页；张永健：《霍菲尔德分析法学对占有、信托概念的新界定》，载《经贸法律评论》2021年第6期。

⁴⁷ 有的立法例认为此claim A并不能对抗具有“更优权利”的人，例如瑞士、荷兰、埃及等，但是，如果严格按照“事实保护”与“权利保护”二分的标准去审视，应当认为此处为对世权，效力应及于除占有人外的所有人，上述立法例不正确，参见张永健：《霍菲尔德分析法学对占有、信托概念的新界定》，载《经贸法律评论》2021年第6期。

⁴⁸ 参见[德]鲍尔、施蒂尔纳著，张双根译：《德国物权法（上册）》，法律出版社2004年版，第155页。

例如占有人同意的占有移转（即使构成欺诈、恐吓）、动产偶至他处（动物运动、帽子被风吹走）、占有人遗失占有物为他人所拾得、承租人租赁期限届满后拒不返还占有、法律规定的正当行为等⁴⁹，此时占有空有自由（Privilege）而无权利（Claim），是一种缺乏保障的“弱自由”⁵⁰。

若此“Claim-Duty”关系被违反⁵¹，则首先产生特定、次生②Claim B (+) — Duty B (+)：原事实占有人有权利（Claim）请求侵占者回复占有，侵占者有义务（Duty）回复占有，此即占有保护请求权；其次，产生③Privilege A (+) — No-Claim A (-)，原事实占有人有以私力排除干涉的自由（Privilege），侵占者无权利（No-Claim）请求原事实占有人不以私力回复占有。“以私力回复占有”即除依靠国家公权力外为法律秩序所容许的回复占有的行为，包括但不限于危急时刻的防御权，追寻权，取回权等，因各国法律秩序不同而不同。

④Privilege B (+) — No-Claim B (-)：对于除占有本权人以外的世界上其他人而言，事实占有人有占有的自由（Privilege），除占有本权人世界上其他人均无权利（No-Claim）请求事实占有人放弃占有。

占有原权是占有的灵魂所在，除本权占有人外，事实占有人对于对世界上一切其他人享有 Privilege+Claim 的双重法律利益，是一种形式完整的“自由权”（强自由）⁵²，但占有原权仍不具有一般物权的效力，原因有三点：第一，由于本权占有人的可能存在，该自由（Privilege）的效力毕竟不一定及于世界上所有不特定人，故只能称之为“准对世权”；第二，占有原权难以脱离事实占有独立存在，权利的时间效力上具有暂时性；第三，占有原权难以获得通常意义上的排他保护，只在特定的条件达成时能够享有排他的权利（Claim）（例如丧失占有状态下，侵夺行为必须满足“禁止之私力”要件）。制度上，最符合此结构的规范设计是日本的占有权制度。

值得一提的是，由于①关系的存在，瑕疵占有人需承受一定的法律负担。即瑕疵占有人须承受向前手占有人返还占有的 Duty A，且瑕疵占有人 No-Claim B 请求前手占有人放弃占有。

2. 占有本权

占有本权，是指“具有占有权能的权利”。占有本权最显著的特点是，占有在应然层面上归属于占有本权人，不论其丧失占有的形态如何。“由于所有权

⁴⁹ 参见谢在全：《民法物权论（下册）》，中国政法大学出版社2011年版，第1225-1226页。

⁵⁰ 关于弱自由的概念，参见雷磊：《法律权利的逻辑分析：结构与类型》，载《法制与社会发展》2014年第3期。

⁵¹ 在霍菲尔德的四组法律关系里，只有涉及他人行为的“权利（claim）—义务（duty）”关系才能被违反。霍菲尔德将能被违反的第一层“权利（claim）—义务（duty）”关系称为第一性关系，而侵害第一性关系所引发的第二层“权利（claim）—义务（duty）”关系称为第二性关系。参见上注36，[美]韦斯利·霍菲尔德著，张书友译：《司法推理中应用的基本法律概念》（修订译本），商务印书馆2022年版，第139-140页。

⁵² 关于强自由的概念，参见雷磊：《法律权利的逻辑分析：结构与类型》，载《法制与社会发展》2014年第3期。

应当实现所有权人对物的完全支配，而实际上的支配则以占有为前提，因此所有权人基于其所有权也拥有占有权。如果所有权人失去了占有，那么法律就应当设法使他重新取得占有。”⁵³不仅所有权如此，所有占有本权皆如此。

在分析占有本权的法律结构之前，此处有必要就相关概念予以澄清。第一，占有本权应当区别于上文所述的“占有原权”。“物权人如构成对物之占有，亦得依占有保护请求权而对抗任意第三人，但其效力之来源，纯粹取决于占有事实存在与否，而非来自于物权及其绝对性。可见，因占有而产生的绝对效力，与因物权而产生的绝对效力，形似而神不似，纵使并存于一人手中，亦各自异其渊源，不可混为一谈。”⁵⁴换言之，占有原权因事实占有而产生，占有本权则独立于事实产生，对前者的保护可谓之“事实性占有的保护”，后者则谓之“权利性占有”的保护，两者无论产生原因还是效力均大相径庭；第二，占有本权应区别于“有权占有”，“有权占有”在语义上应当被理解为“有权的占有”

（正当占有），是特殊的占有，而非“有权去占有”的规范地位，后者实指占有本权。换言之，“有权占有”应该是指有权占有人享有占有的事实状态，是占有本权与事实占有（间接占有）合一的复合体，所以，有权占有人一定是占有本权人，但占有本权人在脱离占有之时并非有权占有人。

占有本权可因性质不同可主要分为两类⁵⁵，一类是对世性占有本权（物权，如所有权、质权、居住权等），一类是对人性占有本权（债权，如租赁权、借用权、保管权等），不同的占有本权权利的结构不一样，具体如下：

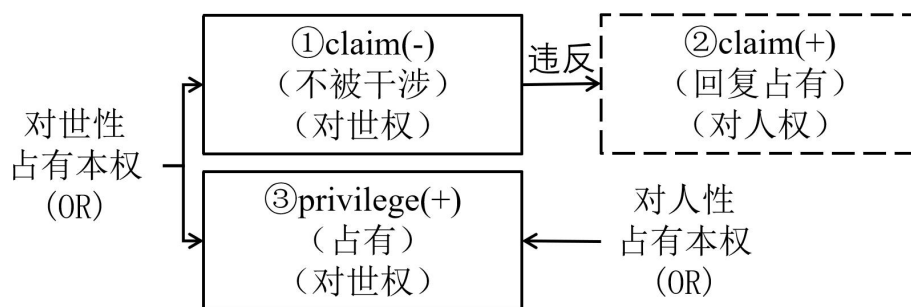


图 5

①Claim C (-) - Duty C (-)：对世性占有本权人有权利（Claim）请求世界上其他人不得干涉其占有，世界上其他人均负有不得干涉对世性占有本权人之占有的义务（Duty）。此系对世、第一性的 Claim (-)。盖因对世性占有本权人总能终局性地获得占有，即使占有本权人从未实施过占有，并不妨碍其请求

⁵³ [德]沃尔夫著，吴越，李大雪译：《物权法》，法律出版社 2004 年版，第 91 页。

⁵⁴ 金可可：《基于债务关系之支配权》，载《法学研究》，2009 年第 2 期。

⁵⁵ 除此两类法律关系外，尚有亲权关系、夫妻关系、监护关系等人身性关系，此处仅聚焦于财产性关系。

返还占有，故此处的干涉当然不必讨论瑕疵与否。若此权利（Claim）被违反，则产生对人、第二性的②Claim D (+) — Duty D (+)：占有本权人有权利（Claim）请求侵占者回复占有，侵占者有义务（Duty）回复占有。此即物权请求权。

对世性的占有本权具有对世、排他的效力，世界上所有不特定人均负有不作为义务，且该权利的实现没有额外的条件（瑕疵之要件），区别于占有本权的孱弱，是真正的“物上关系”⁵⁶。在法律技术上，此项权利在实现上依赖于“物权法定原则”与“公示原则”，故对世性占有本权（债权）并无此权利（Claim），这正是物债二分体系的关键之处。

③Privilege C (+) — No-Claim C (-)：对于世界上其他人而言，占有本权人占有自由（Privilege），世界上其他人均无权利（No-Claim）请求占有本权人放弃占有。

对人性的占有本权没有排他的效力，仅具相对性，“其典型情形，如承租人之租赁物被第三人无权占有。因债权仅具有相对性效力，承租人自然无法向该第三人主张基于租赁关系而生的对租赁物的占有权，进而以此为据请求租赁物的返还。”⁵⁷对人性占有本权人只能依靠其债权请求相对人的帮助。

由此可见，占有本权的核心在于对世性的占有 Privilege (+)。事实上，仅有占有本权人享有此项完整的对世性自由（Privilege），所有其他人的占有自由（Privilege）均有所残缺，原因即根据关联关系，所有其他人均负有不干涉的 Duty (-) 或者回复占有的 Duty (+)。

3. 间接占有

本部分所称“间接占有”指“依据法律关系进行的间接管领”的事实，以下称因间接间接占有事实而产生的权利为间接占有权，其法律结构如下：

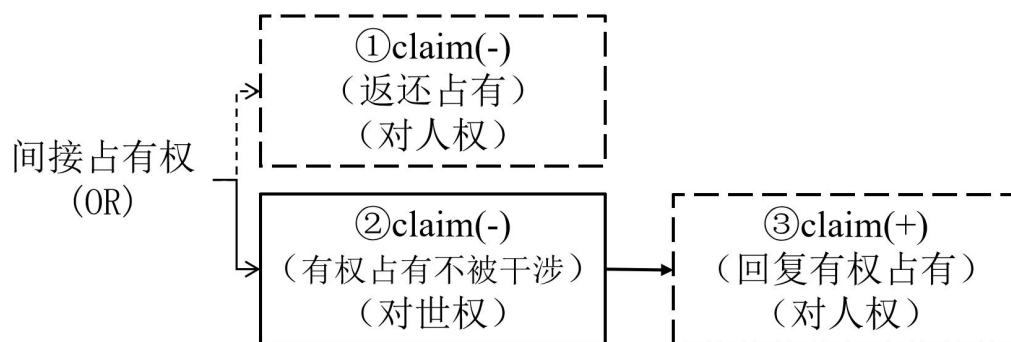


图 6

⁵⁶ 关于“物上关系”的概念，参见张永健：《物权的关系本质——基于德国民法概念体系的检讨》，载《中外法学》2020年第3期。

⁵⁷ 张双根：《占有的基本问题 评〈物权法草案〉第二十章》，载《中外法学》2006年版第1期。相反观点参见金可可：《基于债务关系之支配权》，载《法学研究》，2009年第2期。对此笔者认为，否认对人性占有本权（债权）的对世 Claim (-)（排他效力）是承认物债二分的逻辑必然，即使法律意欲保护此类本权人，也不得循此构造，否则有违法理。

① $\text{Claim D (+)} \dashv \text{Duty D (+)}$ ：在一定条件下或期限后，间接占有人有权利（Claim）请求占有本权人返还占有，占有本权人有义务（Duty）向间接占有人返还占有。

间接占有构成所谓的“法律上支配”，前提条件是要与占有本权人形成一定的法律关系，即德国、中国台湾地区立法例所谓“占有媒介关系”，日本立法例所谓“占有代理关系”⁵⁸，此关系的实质是，将原占有本权人（现间接占有人）占有本权中移转给相对人（现占有本权人），自己通过“隐而未现”的法律关系间接控制着占有物。

② $\text{Claim E (-)} \dashv \text{Duty E (-)}$ ：间接占有人权利（Claim）请求世界上其他人不瑕疵干涉（占有本权人的）占有，世界上其他人有不瑕疵干涉（占有本权人的）占有的义务（Duty）。此系对世、第一性的 Claim (-)，若违反，则产生特定、次生

③ $\text{Claim B (+)} \dashv \text{Duty B (+)}$ ：原事实占有人有权利（Claim）请求侵占者回复占有，侵占者有义务（Duty）回复占有，此即间接占有人占有保护请求权。

间接占有人为何获得保护并不在本文论域之内，但是，通说认为间接占有人对物具有“事实上的管领力”值得商榷，由间接占有的结构可见，所谓的事实上的管领，也是一层隐而未现的法律关系（①），与直接占有（事实占有）的事实上管领可谓完全不同。退一步讲，如果完全相同，何以间接占有人难以适用私力救济权（Privilege A）⁵⁹？事实上，间接占有的本质并非对物的事实管领，而是“在物的法律交往（Rechtsverkehr）过程中的关于占有的一些法律作用”，是法律虚设的支配力⁶⁰，也就是上图所展示的间接占有法律关系。但是，它的法律关系（权利）性质，并不影响它在占有之诉中的事实性——间接占有权的证明仍然被视为事实证明而区别于本权之诉中的占有本权证明。

4. 占有辅助

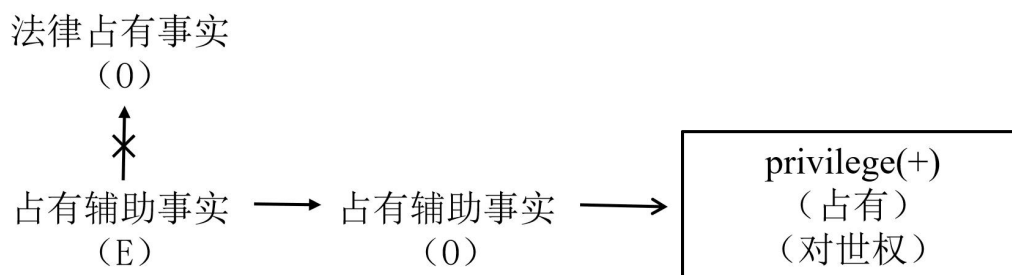


图 7

⁵⁸ [日]我妻荣：《新订物权法》，第 489 页。

⁵⁹ 关于间接占有人的私力救济权的论述，参见吴香香：《〈物权法〉第 245 条评注》，载《法学家》2016 年第 4 期。

⁶⁰ 周梅：《间接占有中的返还请求权》，法律出版社 2007 年版，第 83-87 页。

本部分所称“占有辅助”，是指“不受占有保护的指示性管领事实”，占有辅助的特点是，不享有占有保护请求权。占有辅助事实与事实占有（自己占有）能够同时存在，就指示性关系而言，指示人享有占有原权，而被指示人没有相应的权利，其仅被允许进行管领。

① Privilege D (+) — No-Claim D (-)：对于世界上其他人而言，占有辅助人有占有的自由（Privilege），除占有辅助人世界上其他人均无权利（No-Claim）请求占有辅助人放弃占有。

与霍菲尔德提及的“小虾沙拉”问题类似，此时占有辅助人空有自由（Privilege）而无权利（Claim），权利是残疾的，当占有被侵害之时，他不能单独地寻求法律上的保护，仅能寻求占有原权人的帮助。

5. 关于动产的处分与交付

因本文论述对象为占有的保护与归属，没有论及占有的权利外观与交付，而后者与占有物的处分紧密相关，在此作简单介绍。

在霍菲尔德的视角下，处分行为是一种 Power，而原则上仅有处分权人享有此种 Power，世界上其他不特定人均需承受处分后法律关系改变的 Liability；无权处分人 Disability 对处分权人之物进行处分，处分权人对无权处分人之处分享有 Immunity。但是，为了保护交易安全，在涉及无权处分的交易中，有必要对善意的买受人的合理信赖予以保护，故此，善意取得制度实际上补足了无权处分行为的处分权，使得具有权利外观的无权处分人得以在一定条件下享有处分的 Power。而通说认为，占有正是动产的权利外观⁶¹。

交付与动产之处分而言亦具有重要意义，动产的物权变动以交付为必要（现实交付为原则，观念交付为例外），而“简易交付”“占有改定”“返还请求权让与”中各处分之 Power 何时成就，法律关系如何改变，用上述的几种占有的法律结构可以尝试给出清晰的答案，篇幅所限，只能留待后续解决。

（四） 小结

通过对占有相关法律关系进行检视，我们至少可以得出如下结论：

1. 占有是一个复杂多义的法律概念，具言之，占有呈现出事实与权利的双重面向。就事实面向而言，有关占有的事实可分为构成性占有事实与证明性占有事实，前者足以引起法律关系变动，等同于法理论中法律规则的构成要件，后者则为前者的证成提供论证上的助力。由于制度传统与路径依赖，服务于占有事实面向的占有构成理论无法简单纯化，但这并不影响我们继续检视更为重要

⁶¹ 不同观点参见纪海龙：《解构动产公示、公信原则》，载《中外法学》2014年第3期。

的占有法律关系。

2.占有的法律结构是占有原权、占有本权、间接占有、辅助占有等四种基本结构及其组合。占有的一般含义是指事实占有，由事实占有所产生的权利（占有原权）是形式上完整但内容上不完整的“强自由”（Claim+Privilege）。形式上完整是指兼具权利（Claim）与自由（Privilege）两种规范利益，内容上不完整是指两点，第一，权利（Claim）附带条件，其行使限于特定的侵害形态；第二，自由（Privilege）并非绝对对世，不能涵盖可能存在的占有本权人；第三，占有原权会长时间丧失事实占有而宣告消灭，效力没有终局性。所以，占有原权并非物权（物上关系），可称作“准物权”（准物上关系）。

3.占有权的一般含义是指占有本权中的占有权能，是“权利性占有”，其法律结构为形式内容均完整的“强自由”（Claim+Privilege）。占有本权中应区别于占有原权与有权占有，前者如前所述，后者应理解为“有权的占有”的状态而非“有权去占有”的规范地位，其实质是“事实占有”（间接占有）与“占有本权”合一的复合形态。

4.间接占有不是事实占有，而是“事实性占有”。其本质并非“通过法律关系进行的事实上管领”，而是“法律虚设的支配力”，是法律关系（权利）而非事实。间接占有的权利本质与间接占有享有占有保护并不矛盾，因为占有诉讼中需要证明的事实是间接占有权而非占有本权，故事实占有与间接占有均为事实性占有。

5.占有辅助不是事实占有，其法律结构是“弱自由”（有 Privilege 无 Claim）。

6.动产的处分与交付与霍菲尔德第二矩阵所列法律关系（Power-Liability, Immunity-Immunity）息息相关。

三、《民法典》占有制度的反思与检讨

我国民法上的占有可谓含混不清。第一，就占有的定义而言，我国民事立法表现出越来越犹疑的态度：2004年《物权法（草案）》第287条规定：“本法所称占有，指占有人对不动产或者动产的实际控制与支配”；2005年《物权法（草案）》将该条放在附则第266条第7项，并删除了“支配”二字，立法者似乎意识到“支配”可能涉及对物的“处分”，为了避免出现概念错误，只保留了“控制”；随着2007年《物权法》出台，一直至2021年《民法典》生效，立法均对占有的定义保持了沉默。失去了立法上的定义，可能是一件“史家不幸诗家幸”的事——占有的概念得以在学界继续讨论。因此，昙花一现的立法

并不能说明我国已经接受了诸如德国、台湾地区的“占有客观说”构成理论，学理上尚有很多解释的空间。第二，民法典里有 46 个条文包含“占有”，“占有”一词一共出现了 57 次，但是“占有原权”“占有本权”“占有辅助”“间接占有”等概念均未予以明示或暗示。由于丧失了立法的定义，我们不能确定标准的“占有”是什么，而且 57 个“占有”并不都具有相同的含义，它可能体现为上文所论述的占有多重含义的其中一重或者多重的复合体，我们极易迷失扑朔迷离的占有内涵里。

一部法典至少应满足文义相对固定的特点，这是法典的内在要求，其至少表现为两点：第一，同一语词原则上应该具有相同的含义；第二，退而言之，如果法典里同一语词有多重含义，则该语词含义的类型应当确定，且判断标准应当清晰，否则，在法典的适用上会产生巨大的争议，丧失法律定分止争的效果。故此，实有必要结合本文提出的理论，对《民法典》中的“占有”进行整理与类型化的“实证研究”。

（一）《民法典》“占有”一词的理论分类

《民法典》正文部分法条中“占有”语词的数量、分布的具体情况如下：

同一条文中 “占有”出现次数	条文数量	条文序号
1	31	226、227、228、235、240、 255、256、263、269、272、 312、323、324、331、340、 344、346、366、394、405、 425、457、458、459、547、 720、725、749、750、751、 953
2	2	459、447
3	4	460、461、748、1239
4	1	1242
6	1	462
共计57个		共计46条

表 3

笔者结合前文所述四种占有法律结构，对此 57 个占有予以分类如下：

序号	“占有”语词的概念内涵	“占有”数量	同一内涵“占有”分类及所处位置
1	占有本权的占有权能	17	【支配权】255、256、269、324
			【所有权】240、263、272
			【用益物权】323、331、340、344、362、366
			【担保物权】394*、425*、447第1
			【租赁权】748第1
2	事实性占有（事实占有或间接占有）	31	【无涉本权】226、227、228、312*、405、447第2、457、459第3、460第3、460第3、462第2、462第4-6、547、720、725、749、750、751、953
			【有权占有】458*、1239第1-3
			【无权占有】235、461第1-3、1242第1-4
3	仅限事实占有	8	【无涉本权】462第1、462第3、748第2-3、
			【无权占有】459第1-2、460第1-2
4	占有辅助	0	无
总计		57	42条

表 4

分类后，每一个“占有”的涵义清楚明了，并且均可符合文中第二部分所述的法律结构，在法律解释与适用上十分便利。但是，带*的“占有”仍需要进一步澄清：

首先，第 394 条“债务人或者第三人不转移财产的占有”的表述实际是对抵押权占有权能的否定，抵押权并无占有权能；其次，第 425 条“债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的”的表述有两重内涵，此“占有”一方面表示动产质权有占有权能，另一方面还应表示“仅限事实占有”的设立方式。至于后者为何不包括间接占有，也即为何禁止以“占有改定”的方式设质，原因有两点：第一，《民法典》第 228 条对占有改定的适用范围限定为“动产物权转让”而不包括“设立”；第二，质权若不以直接占有为基础恐丧失留置效果⁶²。出于表格的精简，本文为了不使第 425 条重复出现，故在此对其特殊的双重含义进行说明；再次，第 312 所谓拾得人占有，既可能构成无权占有（例如拾得人据为己有），也可以构成有权占有（拾得人构成无因管理⁶³），出于相同目的，亦未体现于表格。对带*的第 458 条解释下文将在检讨处详述。

⁶² 参见刘家安：《物权法论》（第二版），中国政法大学 2015 年版，第 181 页。

⁶³ 参见隋彭生：《对拾得物无因管理的占有是有权占有》，载《华东政法大学学报》2010 年第 1 期。

（二）基于理论分类的归纳与检讨

结合上述分类结果，我们能发现如下现象：第一，代指权能的占有（上述 1 类），除租赁权一项债权外⁶⁴，其余均为物权，此现象似乎与“租赁权物权化”现象遥相呼应；第二，代指事实的占有，原则上指事实性占有（事实占有或间接占有）（上述 2 类），但也存在仅指事实占有的例外（上述 3 类）；第三，《民法典》未规定占有辅助（上述 4 类），亦无其他有关占有辅助的暗示。基于以上现象，我们可以对《民法典》进行反思：

首先，《民法典》第 458 条中“占有”的如何理解？《民法典》第 458 条规定：“基于合同关系等产生的占有，有关不动产或者动产的使用、收益、违约责任等，按照合同约定；合同没有约定或者约定不明确的，依照有关法律规定。”第一，此处“占有”何指？根据法工委及最高院的解说，此条的规范内容为“有权占有的适用”。根据本文第二部分的结论，有权占有实际上等于“事实性占有”（事实占有与间接占有）加上“占有本权”，“占有本权”“间接占有”基于合同关系等产生尚且可以理解，“事实占有”如何通过法律关系产生？

其次，司法实践中“间接占有”与“占有辅助”是法律适用中常用的概念，而《民法典》则对此保持沉默。实际上，“占有辅助”采消极性规定并无不当，盖因“占有”本身可在解释时涵盖“存在指示性关系”这一消极要件，从而将“占有辅助”排除在占有之外，但如何处理“间接占有”法律文本缺失所造成的法律漏洞呢？

笔者提议，可将第 458 条中的“占有”限定为“间接占有”，可解决上述问题。第一，由本文第二部分间接占有权的法律结构可知，间接占有最根本的特质是享有“隐而未发”的权利（Claim），而“基于合同关系等产生”正与“权利（claim）—义务（duty）”关系匹配；第二，间接占有本质上是“事实性权利”，而权利是可以由法律关系“产生”的，在文义上无矛盾；第三，间接占有的存在一定预示着存在事实占有，而相反却不成立，间接占有比事实占有更具有一种概念上的“关联特质”，故此，将此处“占有”理解为“间接占有”更能表达出第 458 条的规范意旨；第四，能解决立法上没有间接占有概念的困境。

⁶⁴ 通说认为租赁权是一项“物权化的债权”实值商榷。租赁权不能简单地直接定性为债权，其在结构上可分为两个阶段：租赁物交付前的纯债权部分（对人权）与交付后的债权、支配权混合部分（对人权与对物权），后者又可进一步分为债权部分（对人权）与支配权部分（对世权）。参见上注 35 王涌：《私权的分析与建构——民法的分析法学基础》，北京大学出版社 2019 年版，第 253 页；参见上注 57，金可可：《基于债务关系之支配权》，载《法学研究》，2009 年第 2 期。

结论

事实还是权利，实然还是应然，占有不仅是理论的分歧点，更是理论的切入点。将占有一分为二，一边是不问权利的事实状态（占有原权、间接占有），另一边是不问事实的规范状态（占有本权），进一步区分出占有的缺陷状态（占有辅助）与复合状态（有权占有），辅之以霍菲尔德理论的法律关系界分，此种理论进路能够很好地分析出占有的法律结构。结合占有的法律结构对现行法予以审视，发现《民法典》对占有的只言片语并不具有建构完备占有制度的立法基础，必须加以解释与续造。在笔者看来，占有辅助尚可消极判断交予司法机关自行判断，无须立法赘言；间接占有却是《民法典》未言的隐痛，必须藉由对第 458 条中“占有”的限缩解释以明定“间接占有”在体系中的位置，从而实现体系的周延。

本文秉持这样的一种理念：“至少就占有制度而言，不深入基础概念而仅限于表面的文字点评几乎是没有任何意义的。”⁶⁵民法占有渊源的悠久、理论的深化、制度的变迁，无一不加深了我们理解此概念的难度。但是，好的理论可以化繁为简，减轻我们思维的负担，更为重要的是，它可以帮助我们将对民法概念的思考“抽象到稀薄的程度”，霍菲尔德分析法学正是这样的理论，基于此，含混不清的占有也可以被条分缕析。概念史固然重要，但我们不能要求法官们在法律适用的工作中总是从罗马开始，我们更需要概念的法律结构，因为历史与制度总是变化的，而法理是永恒的。

⁶⁵ 刘家安：《含混不清的“占有”——〈物权法〉草案“占有”概念之分析》，载《中外法学》2006 年第 2 期。

参考文献

- [1] 朱庆育：《物权行为的规范结构与我国之所有权变动》，载《法学家》2013年第6期
- [2] 张永健：《物权的关系本质——基于德国民法概念体系的检讨》，载《中外法学》2020年第3期
- [3] 张永健：《霍菲尔德分析法学对占有、信托概念的新界定》，载《经贸法律评论》2021年第6期
- [4] 吴香香：《占有保护缘由辨》，载王洪亮等主编《中德私法研究》（第11卷），北京大学出版社2015年版
- [5] 吴香香：《〈物权法〉第245条评注》，载《法学家》2016年第4期
- [6] 刘家安：《含混不清的“占有”——〈物权法〉草案“占有”概念之分析》，载《中外法学》2006年第2期
- [7] 贾婉婷：《罗马法中关于占有关系的理论——兼论现代法学理论及立法》，载《比较法研究》2009年第3期
- [8] 贾婉婷：《罗马物权法——所有权与占有》，中国法制出版社2019年版
- [9] 雷磊：《法律权利的逻辑分析：结构与类型》，载《法制与社会发展》2014年第3期
- [10] 雷磊：《法律规则的逻辑结构》，载《法学研究》2013年第1期
- [11] 孟勤国：《占有概念的历史发展与中国占有制度》，载《中国社会科学》1993年第4期
- [12] 隋彭生：《对拾得物无因管理的占有是有权占有》，载《华东政法大学学报》2010年第1期
- [13] 冉昊：《论权利的“相对性”及其在当代中国的应用——来自英美财产法的启示》，载《环球法律评论》2015年第2期
- [14] 金可可：《基于债务关系之支配权》，载《法学研究》，2009年第2期
- [15] 张双根：《占有的基本问题——评〈物权法草案〉第二十章》，载《中外法学》2006年版第1期
- [16] 纪海龙：《解构动产公示、公信原则》，载《中外法学》2014年第3期
- [17] 王夏昊：《本体论同构与法律权利概念观分异——基于分析路径的权利研究》，载《法制与社会发展》2021年第4期
- [18] 孟勤国：《论占有、占有权能和占有权》，载《法学研究》1985年第2期
- [19] 王利明：《关于占有、占有权和所有权问题》，载《法学评论》1986年第1期
- [20] 戴昕：《数据界权的关系进路》，载《中外法学》2021年第6期
- [21] 芦雪峰，李凤章：《反思占有“事实”说》，载《东方法学》2014年第1期
- [22] [意]萨尔瓦多里科波诺，贾婉婷：《罗马法中关于占有关系的理论——兼论现代法学理论及立法》，载《比较法研究》2009年第3期
- [23] 王涌：《私权的分析与建构——民法的分析法学基础》，北京大学出版社2019年版
- [24] 刘家安：《物权法论》（第二版），中国政法大学2015年版
- [25] 周枬：《罗马法原论（上）》，商务印书馆2014年版
- [26] 尹田：《法国物权法》（第二版），法律出版社2009年版
- [27] 高鸿钧等主编：《英美法原论（上）》，北京大学出版社2013年版
- [28] 江平，米健：《罗马法基础》（修订本第三版），中国政法大学出版社2004年版

中国政法大学法学院军都法学论文大赛

- [29] 周梅：《间接占有中的返还请求权》，法律出版社 2007 年版
- [30] 史尚宽：《物权法论》，中国政法大学出版社 2000 年版
- [31] 谢在全：《民法物权论（下册）》，中国政法大学出版社 2011 年版
- [32] 刘士国、牟宪魁、杨瑞贺译：《日本民法典》，中国法制出版社 2018 年版
- [33] 戴永盛译：《瑞士民法典》，中国政法大学出版社 2016 年版
- [34] 台湾大学法律学院、台大法学基金会编译：《德国民法典》，北京大学出版社 2016 年版
- [35] 戴永盛译：《奥地利普通民法典》，中国政法大学出版社 2016 年版
- [36] 陈国柱译：《意大利民法典》，中国人民大学出版社 2010 年版
- [37] 王洪亮等主编《中德私法研究》（第 11 卷），北京大学出版社 2015 年版
- [38] 赵萃萃：《英美财产法之 Estate 研究》，山东大学 2010 年博士论文
- [39] 吴香香：《功能视角下的占有概念》，中国政法大学 2010 年博士论文
- [40] [德]萨维尼著，朱虎，刘智慧译：《论占有》，法律出版社 2007 年版
- [41] [德]马克思·卡泽尔著，田士永译：《罗马私法》，法律出版社 2018 年版
- [42] [德]鲍尔、施蒂尔纳著，张双根译：《德国物权法（上册）》，法律出版社 2004 年版
- [43] [德]沃尔夫著，吴越，李大雪译：《物权法》，法律出版社 2004 年版
- [44] [德]罗伯特·阿列克西著，舒国滢译：《法律论证理论》，中国法制出版社 2002 年版
- [45] [意]阿尔贝托·布尔代塞，翟远见译：《罗马物权法》（第四版），中国政法大学出版社 2022 年版
- [46] [日]我妻荣著，罗莉译：《新订物权法》中国法制出版社 2008 年版
- [47] [奥]伽里布菴·库齐奥，[奥]海尔穆特·库齐奥著，张玉东译：《奥地利民法概论——与德国法相比较》，北京大学出版社 2019 年版
- [48] [美]韦斯利·霍菲尔德著，张书友译：《司法推理中应用的基本法律概念》（修订译本），商务印书馆 2022 年版
- [49] [英]弗雷德里克著，于子亮译：《普通法上的占有》，中国政法大学出版社 2013 年版
- [50] T. F. Martin, *Possession as a Root of Title*, 61 University of Pennsylvania Law Review 647 (1913)
- [51] Francis S. Philbrick, *Seisin and possession as the basis of legal titles*, Iowa Law Review, Vol 24, 1939
- [52] Frederick Pollock, Robert Samuel Wright, *An Essay on Possession in the Common Law*, Oxford At The Clarendon Press, 1888
- [53] F. Bozza, *Il possesso*, Napoli, 1935
- [54] W. T. Murphy and Simon Roberts, *Understanding Property Law*, Sweet & Maxwell, 3rd ed., 1998
- [55] Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, Yale University Press, 1919
- [56] Werner Schubert, *Die Entstehung der Vorschriften des BGB über Besitz und Eigentumsübertragung*, Berlin
- [57] Rudolf von Jhering, *DER Besitz*, in: *Jheringstüahrcher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen privatrechts*, Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1893
- [58] Bekker, *zur Reform des Besitzrechts*, Jherings Jahrb, Bd.3